

1521581-60.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO - ADEQUADA APREENSÃO, PRESERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DROGA À AUTORIDADE POLICIAL, COM ENCAMINHAMENTO FINAL À PERÍCIA - DESNECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SACOLA EM QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS AS PORÇÕES DO ENTORPECENTE - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1521581-60.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521581-60.2021.8.26.0228 - 2021/001107

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL DA SILVA BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

GABRIEL DA SILVA BRITO foi denunciado no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 c.c art. 61, II, j do CP, porque, aos 07 de setembro de 2021, por voltadas 02h30min, na R. Frei Luis de Leon, altura do número 90, no bairro Cidade Dutra, nesta cidade e comarca, agindo em conjunto e unidade de propósitos e envolvendo o adolescente infrator Luis Mario da Silva Moreira, guardava tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 127 (cento e vinte sete) invólucros plásticos contendo substância entorpecente denominada cocaína; 4 (quatro) embalagens contendo a substância entorpecente denominada tetrahydrocannabinol (THC); 37 (trinta e sete) invólucros contendo a substância entorpecente denominada cocaína, sob a forma de "crack" e 3 (três) frascos contendo substância entorpecente denominada Tricloroetileno, conhecido vulgarmentecom "lança perfume", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida aos 14.09.2021(fls. 134/135).

O réu constituiu advogado nos autos e apresentou defesa prévia às fls. 156/170.

Ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia às fls. 185/188.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pediu a condenação, nos termos da denúncia.

Já a Defesa pediu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante da calamidade, a fixação da pena do mínimo legal, a imposição do regime menos gravoso e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

Inicialmente, convém mencionar em sede de preliminar, que não houve quebra da cadeia de custódia por inobservância ao quanto estabelecido no art.158-B, do CPP, tal como pretende crer a defesa. Isto porque, as drogas foram coletadas, acondicionadas e devidamente lacradas, com numeração própria, pelos agentes da polícia, para o fim de serem enviadas ao Instituto de Criminalística para realização de exame preliminar de constatação e, posteriormente, exame toxicológico definitivo, firmado por perito oficial.

Neste contexto, não há que se falar em inidoneidade do meio empregado pelos policiais responsáveis pelas diligências, que a todo tempo, se pautaram pelo procedimento previsto em lei, desde o encontro das substâncias até a realização dos exames periciais.

Insta salientar, inexistir qualquer disposição legal quanto à obrigatoriedade em se apresentar fotografias do material apreendido pela autoridade policial, já que o art.158-B do CPP estabelece a "descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento".

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...) TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Não evidenciada a quebra da cadeia de custódia, sobretudo porque a inexistência de fotografias dos vestígios e do local em que foram encontrados não torna a prova ilegítima, ausente qualquer indício de sua adulteração. Artigo 158-B, inciso III, do CPP, que não obriga à tomada de fotografias na ilustração do vestígio encontrado. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo e transportando 108 porções de maconha (247g) e 167 porções de cocaína (63,36g). Versão do acusado, de que foi incriminado injustamente por descumprir suposto conchavo firmado com policiais em data pretérita, que além de inverossímil, sucumbiu ao mais da prova produzida. Depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, que se mostraram firmes, coesos e coerentes. Condenação mantida (...) (TJSP, Apelação nº 1500977-15.2021.8.26.0540, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15ª Câmara de Direito Criminal, J: 06/08/2021)

PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP - INOCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DO RÉU EM RAZÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NA SEQUÊNCIA - PROCEDIMENTO DO REFERIDO DISPOSITIVO, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO UMA

OBRIGATORIEDADE, PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL- PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO-CRIME - NULIDADE - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - TRÁFICO - ADEQUADA APREENSÃO, PRESERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DROGA À AUTORIDADE POLICIAL, COM ENCAMINHAMENTO FINAL À PERÍCIA - DESNECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SACOLA EM QUE ESTAVAM ACONDICIONADAS AS PORÇÕES DO ENTORPECENTE - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APR: 15060071020208260526 SP 1506007-10.2020.8.26.0526, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 01/06/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/06/2021)

Da mesma forma, desnecessário autorização do proprietário do veículo para ingresso em seu interior, diante da situação de flagrância que se encontrava, já que as drogas estavam sob o banco do passageiro, circunstância esta que levou a apreensão do veículo e encaminhamento ao distrito policial.

No mérito, a pretensão acusatória é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 10), boletim de ocorrência registrado sob o nº AM9182-2/2021 (fls. 1/9), auto de exibição e apreensão (fls. 33/34), laudo de constatação preliminar (fls. 40/43, laudo de exame toxicológico definitivo (fls. 211/214), bem como pela prova oral constante nos autos.

Nesse ponto, cabe ressaltar o mencionado laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 211/214) que concluiu pela existência as substâncias entorpecentes acima descritas: "(...) A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); (...)A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); (...) A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e, foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); (...) A análise do material descrito fez o uso de Espectroscopia na região do Infravermelho com Transformada de Fourier e, foi DETECTADA presença da substância TRICLOROETILENO, constante na lista B1 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) e na Lista D2 (Lista de insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos - Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).".

A autoria também é certa.

Segundo consta na denúncia, policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos após receberem a informação de que ali estaria ocorrendo a prática do tráfico de drogas, mais precisamente com a utilização de um veículo, estacionado defronte a uma adega. No local, logo avistaram o acusado que, ao notar a presença dos policiais, jogou algo para cima de um telhado. Em seguida, avistaram o veículo marca "Chevrolet", modelo Agile LT, cor prata, placas EZH9150-SP que se encontrava fechado.

No entanto, através dos vidros, conseguiram visualizar uma pequena bolsa com a inscrição PCC, dinheiro e papéis (fls.45). Todos que ali estavam foram submetidos a revista pessoal e, em poder da testemunha Mozart, foram localizadas três embalagens contendo cocaína. Mozart informou que comprou a droga da pessoa do acusado e do adolescente Luis Mario (fls.16).

Com a ajuda de um chaveiro, o veículo foi aberto e no seu interior localizado grande quantidade de substâncias entorpecentes acima descritas, além da quantia de R\$ 348,30 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos em dinheiro) e anotações do tráfico. Apurou-se que o veículo pertencia a Aline de Miranda Martins, esposa do acusado (fls.04).

Em solo policial, o réu Gabriel da Silva Brito negou os fatos a ele imputados. Disse que estava em uma adega ingerindo bebidas alcóolicas e o veículo de sua esposa estava parado na porta do local, quando Policiais Militares chegaram e abordaram todos que ali estavam, se apossando da chave do carro que estava em seu bolso. Afirmou ainda desconhecer a droga encontrada no veículo e que não pratica tráfico de drogas (fls.18/19).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou o crime a ele imputado. Afirmou que no dia dos fatos estava com o veículo de sua esposa estacionado em frente à adega, com as portas abertas e som ligado, sendo que a chave se encontrava na ignição, para alimentar a bateria do veículo. Neste dia havia consumido droga e estava bebendo na adega, quando os policiais chegaram e abordaram todos que lá estavam, afirmando que se tratava de uma averiguação, razão pela qual todos foram levados para delegacia. Antes, porém, todos foram encaminhados para o final da viela, longe do local em que o seu veículo estava. Nega que os policiais tenham indagado acerca de quem seria o proprietário do veículo. Somente na delegacia teve ciência, com a chegada de seu veículo no guincho, de que foram encontradas as drogas em seu interior. Ficou sabendo que o menor de idade que teria colocado tais drogas no interior do veículo, já que o mesmo estava aberto, com acesso para todos. Não sabe explicar o motivo pelo qual o veículo chegou guinchado na delegacia. Também não presenciou o momento em que as drogas foram encontradas. Afirmar que na época dos fatos havia brigado com sua esposa e estava fora de casa há uma semana, na posse do veículo. Informa que o local em que estava é conhecido como ponto de droga. Não sabe informar a quem pertencia a pochete apreendida. Também não presenciou o momento em que o chaveiro abriu o veículo na delegacia, pois ficou mais de doze horas na viatura. Nega que tenha vendido droga para Mozart e afirmou que no momento da abordagem havia diversas pessoas, como duas garotas, um cadeirante e o dono da adega. Disse que tudo foi muito rápido e de repente todos já estavam na delegacia.

A fala do réu, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou o delito que lhe é imputado.

Vejamos a prova do contraditório:

A testemunha Waldemar Garcia de Oliveira Junior, policial militar, declarou que realizavam patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atenderem a ocorrência de que indivíduos estariam vendendo entorpecentes e que no local, também havia um veículo de cor prata, estacionado em frente a uma adega local em que a droga seria guardada. Chegando ao local visualizaram o réu jogando algo para cima do telhado não sendo possível visualizar o que era. Em busca pessoal disse que localizaram com indivíduo de nome Mozart, 03 pinos de cocaína sendo que com os demais, nada foi encontrado. No referido veículo constatou-se, pelo lado de fora, que havia uma pochete no banco do passageiro com a sigla "PCC" além de entorpecentes, dinheiro e papéis. Indagado aos abordados sobre a quem pertencia o veículo, ninguém se manifestou razão pela qual todos foram encaminhados à delegacia. Disse que o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia. Relatou que em solo policial apareceu a pessoa de nome "Aline", informando que o veículo era seu e que o réu era seu esposo. O veículo foi aberto por um chaveiro sendo que as drogas foram localizadas no banco do passageiro. Na ocasião o réu ainda teria dito que poderiam quebrar o vidro do automóvel, pois todos o conheciam no local em

que foi abordado. Não conhece o réu de outras abordagens e que tanto as características do veículo e do réu, eram as mesmas informadas via COPOM. Declarou que a morte de outro policial ocorrido na região dos fatos é fato notório, sendo inclusive matéria nos noticiários. Disse que no momento em que chegaram à diligência, não presenciou nenhum ato de traficância do réu, porém, suas características eram as mesmas repassadas, além do relato do outro abordado Mozart teria dito que comprou as drogas do réu. Enfatizou que pelo COPOM foi irradiado a existência de um veículo na Rua Frei Luiz de Leon, de cor prata, e que havia cinco pessoas ao redor do veículo além de duas garotas, sendo informado também, as características do réu. A remoção do veículo ocorreu com um guincho acompanhado da viatura de número 27111, que estava preservando o local. Esclareceu que o pai de uma das garotas, que aparentava ser menor de idade, apareceu no momento da abordagem chamando-a; a outra seria namorada de um dos abordados que, posteriormente, avisou a Sra. Aline, dona do veículo, de todo o ocorrido. Disse que foi ouvido uma vez na delegacia, no período da tarde, assim como seu colega de farda, Sd. Oliveira. Relatou que a chave do automóvel foi apresentada na delegacia posteriormente por um menor de idade acompanhado, inclusive, pelo patrono do réu e que referido menor não estava no momento da abordagem.

Semelhante relato foi apresentado pela testemunha Robson Oliveira Freire, policial militar, também presente na diligência, que declarou ainda que o confronto entre policiais e traficantes, que vitimou um policial, teria ocorrido a menos de uma semana e que a referida adega estava fechada.

Com efeito, o agente público de segurança não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à minguia de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais demonstraram de modo firme e convincente o flagrante ocorrido, descrevendo toda a ocorrência realizada até a apreensão das drogas no interior do veículo. Segundo seus relatos, houve uma denúncia acerca de tráfico de drogas no local, na qual foi relatado que um veículo estacionado na frente de uma adega estava sendo utilizado para vender drogas. Feita a averiguação, no interior do veículo, cuja proprietária é esposa do réu, foram encontradas as drogas apreendidas, além de dinheiro trocado e anotações de contabilidade do tráfico de entorpecentes.

Já a versão apresentada pelo réu, de que seu veículo encontrava-se com as portas abertas e, portanto, qualquer um poderia ter colocado as drogas em seu interior, não condiz com as provas dos autos. Isto porque, foi necessário guinchar o veículo até a delegacia, pois o mesmo se encontrava trancado, o qual somente foi aberto com um chaveiro.

Note que as declarações prestadas pelo adolescente Luis Mario da Silva Moreira, de que teria se utilizado do veículo do réu para vender drogas, não convence. Primeiro porque não veio em Juízo para corroborar tais assertivas e, segundo, porque o próprio menor disse desconhecer o réu, e, assim, não faz qualquer sentido uma pessoa utilizar-se do veículo de um desconhecido para vender drogas, sem qualquer

objeção de seu dono, que inclusive se encontrava no local dos fatos, salientando que referido automóvel estava em frente à adega em que estava o réu, sendo impossível este não perceber qualquer movimentação anormal no interior e seu próprio veículo.

Já as drogas que se encontravam no interior do veículo estavam visíveis, pois estavam sob o banco do passageiro, juntamente com uma pochete inscrita com as siglas de uma grande facção criminosa, além de uma quantia em dinheiro e anotações do tráfico.

Outro fato curioso é o motivo pelo qual o réu não se identificou como proprietário do veículo. Isto porque, se de fato desconhecia a existência das drogas em seu interior e se não tinha nada a temer, bastaria se identificar e pronto. Contudo, quedou-se inerte, o que levou, inclusive, a polícia a encaminhar todos que lá estavam para averiguação, desfecho este que seria diferente caso o réu tivesse se identificado de pronto.

Inegável, também, que a destinação dos entorpecentes seria o comércio ilícito, diante da quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, circunstâncias e local da apreensão.

Ademais, não é crível afirmar-se que os policiais apreenderam substancial quantidade de entorpecente para incriminar inocente, que sequer conheciam até a data dos fatos.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não se admitem insurgências generalizadas contra depoimentos de servidores policiais. Presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação ao réu, que os motivassem a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente.

A versão exculpatória do réu, portanto, mostra-se falsa quando confrontada aos depoimentos policiais, que narram, de forma uníssona, que no veículo utilizado pelo acusado foram encontrados os entorpecentes, os quais, certamente, eram destinados à comercialização, até mesmo porque estavam acompanhados de dinheiro trocado e anotações semelhantes a contabilidade, aliados aos testemunhos de Victor e Mozart.

Com efeito, o ônus de provar situação diversa da citada é do réu, como ensina Damásio de Jesus, o que não ocorreu no presente caso:

"Em processo penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É a regra contida na primeira parte da disposição. Assim, a prova deve ser feita por quem alega o fato, a causa ou a circunstância. Se o Ministério Público oferece denúncia contra o réu por crime de homicídio, incumbe ao órgão da acusação demonstrar a prática do fato e sua autoria. No tocante ao fato concreto cometido pelo sujeito, incumbe à acusação a prova dos elementos do tipo, sejam objetivos, normativos ou subjetivos. Em relação aos delitos materiais, a prova acusatória deve estender-se à demonstração da realização da conduta, da produção do resultado e do nexo de causalidade entre uma e outro. A prova do dolo e da culpa, elementos do tipo, incumbe também à acusação (contra, no sentido de que em decorrência da demonstração do dolo e da autoria o dolo é presumido: TJRJ, ACrim 1.316, RT 649/302). Agora, se o réu, na resposta escrita (art. 396 e 396- A), alega ter agido em legítima defesa, a ele compete a prova da excludente da ilicitude. O acusador deve provar a realização do fato; o acusado, eventual causa excludente da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade ou extintiva da punibilidade."

O fato é que, trazer consigo, é fato típico penal e com o acusado foram encontrados

os entorpecentes aqui descritos, especificamente dentro de uma pochete, sendo que a ação dos policiais militares resultou na apreensão das referidas drogas. Assim sendo, diante desse cenário não há que se falar em ausência de justificativa para a abordagem policial.

Patente, portanto, a traficância.

Por outro lado, durante a instrução processual não se confirmou a causa de aumento inserido no art. 40, VI da lei 11.343/06 (envolver ou visar a atingir criança ou adolescente).

Com efeito, em que pese o comparecimento do adolescente Luis Mario da Silva Moreira em sede policial admitindo a traficância, tal circunstância não serve a justificar a incidência da aludida causa de aumento, notadamente porque não confirmada em Juízo.

Ademais, nada há nos autos que indique o exercício da mercancia ilícita juntamente com o réu e, nem mesmo, que o acusado tenha se utilizado do adolescente inimputável para afastar sua responsabilidade penal. Na verdade, trata-se de mera suposição, que não restou cabalmente demonstrada nos autos.

Note que o adolescente não foi ouvido nos autos e, conforme relatado dos policiais militares, sequer estava presente no momento da abordagem.

De todo modo, a responsabilidade infracional do adolescente não restou evidenciada, eis que homologado o arquivamento do procedimento existente junto à Vara da Infância e Juventude (fls.325).

Da mesma forma, não há que se falar na incidência da agravante pelo delito ter sido cometido em ocasião de calamidade pública (CP, art. 61, II, j), pois não há evidências de que tal situação esteja atrelada à conduta praticada pelo réu.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ: A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Na mesma toada, é o entendimento do E. TJSP:

(...) Não incidência da agravante inserta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal - Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre a pandemia ocasionada pela COVID-19 e a conduta do recorrente. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1516331-80.2020.8.26.0228; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/07/2021; Data de Registro: 13/07/2021).

(...) Segunda fase. Agravante da calamidade pública. Art. 61, II, j. Necessidade de afastamento. Circunstância que se caracteriza quando o agente se aproveita da situação de calamidade. Compensação integral da confissão com a reincidência. Acréscimo de 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos de reclusão. Regime fechado mantido. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500619-74.2021.8.26.0047; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis; Data do Julgamento: 09/07/2021; Data de Registro: 09/07/2021).

Destarte, assentes estão a materialidade e autoria delitiva, e a conduta do réu subsume-se, in totum, ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP e art. 42, da Lei 11.343/06, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste

crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Anoto que há condenação definitiva alcançada pelo período depurador da reincidência (CP, art. 64), que pode ser sopesada como maus antecedentes: 1) Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal. Ação Penal: 0068716-80.2010.8.26.0050, Trânsito em julgado para a Defesa em 15/09/2014 (Art. 180 "caput" do(a) CP - fls. 119). Assim, parto da pena-base aumentada de 1/6 (um sexto), ou seja, cinco anos e dez meses de reclusão e a solver quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal. Ação Penal: 0089487-21.2006.8.26.0050, extinção da punibilidade em 05/06/19 (Art. 157 § 2º, II do(a) CP - fls. 55), razão pela qual agravo a pena em 1/6, totalizando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

Não é o caso de aplicação da causa de diminuição estabelecida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes e reincidência do acusado.

O fato de se considerar maus antecedentes ou reincidência, nesta etapa da dosimetria da pena, para se afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 não implica em "bis in idem". Elas possuem finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, gerando efeitos diversos. Ser primário e com bons antecedentes é condição 'sinequa non' para que o traficante eventual possa merecer a causa especial de diminuição de pena. E o acréscimo pelo fato de o agente ter sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, consubstancia agravante a ser aplicável em todo e qualquer processo criminal.

A matéria não é nova e já foi enfrentada com vagar pelo c. STJ:

"Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - Por decorrer de expressa previsão legal descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inexistente bis in idem na utilização da reincidência como agravante e para justificar o afastamento do tráfico privilegiado, pois é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas da dosimetria da pena, gerando efeitos diversos. Precedentes. - Hipótese em que o tráfico privilegiado não foi reconhecido com base na reincidência do acusado, fundamentação idônea e que não enseja constrangimento ilegal. [...] - Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 362.018/SP, 5ª T., Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.16, DJe 16.11.16).

Ainda:

"Apenas ressalto que, consoante reiterada jurisprudência, a valoração dos maus antecedentes na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado.". (STJ, HC 452.783/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, publicado 07.08.18).

Não há, portanto, bis in idem.

Por tudo isto, diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível a sua incidência, já que a

benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido, prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.

Assim, levando em consideração tais elementos, nego o benefício de redução da pena. Torno, portanto, definitiva a pena fixada alhures.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o fechado, tendo em vista o que dispõe o art. 33, § 3º do CP, e a teor do art. 2º da lei federal 8.072/90, pois o crime de tráfico é equiparado a hediondo. A imposição de regime mais brando mostra-se incompatível com a gravidade do crime praticado.

O montante da pena e o crime cometido não permitem quaisquer substituições ou favores legais.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa, para o delito, no padrão unitário, segundo o salário-mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e condeno GABRIEL DA SILVA BRITO, RG 43.629.771/SP, filho de Francisco de Assis Brito e Rosângela Batista da Silva, nascido aos 03.02.88, natural de São Paulo-SP, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes fixados no valor mínimo legal, por infração aos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizam o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao acusado pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas, bem como eventual contraprova, se acaso tal providência ainda não tiver sido realizada, nos termos do art. 32 e parágrafos da Lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Quanto ao veículo apreendido, com fundamento no art. 63 da Lei 11.343/06, decreto sua perda em favor da União e determino a venda em leilão.

Declaro a perda dos demais objetos apreendidos com o réu (pochete e caderno de anotações - fls. 33/34), porquanto relacionados à traficância. Autorizo a destruição.

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 21 de junho de 2022

Daniela Pazzeto Meneghini Conceição

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA